

1500161-23.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o acusado realizava o tráfico, o que ensejou o patrulhamento pelos castrenses pelas vias da cidade, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500161-23.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500161-23.2022.8.26.0047 - 2022/000139

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA, vulgo 'Romano', qualificado nos autos (fl. 8), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, trazia consigo e mantinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 21 (vinte e uma) porções de cocaína, de peso líquido total de 5,37g (cinco gramas e trinta e sete centigramas), e 12 (doze) pedras de crack, de peso líquido total de 1,63g (um grama e sessenta e três centigramas) [fls. 85/88].

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 83).

O acusado foi notificado (fl. 110) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 115/118), a denúncia foi recebida (fls. 122/123).

Em instrução foram inquiridas três testemunhas e o réu interrogado (fl. 153).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia e do d. Defensor, pela fixação da pena no mínimo legal, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº

11.343/06, reconhecendo-se a atenuante da confissão, fixando-se regime inicial de pena aberto ou semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pela aplicação da detração penal (fl. 153). É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e pelos laudos periciais da substância entorpecente (fls. 39/41, 70/75) e laudo pericial realizado na balança apreendida (fls. 99/101).

Na fase policial o acusado permaneceu em silêncio (fl. 8), tendo aduzido em Juízo que confessa os fatos. Disse que as drogas apreendidas pertenciam ao réu. Praticou o tráfico de drogas porque estava passando por dificuldades e precisava pagar a pensão alimentícia de sua filha. Pegou as drogas por duas semanas para poder pagar as contas básicas da casa do réu e de sua filha. Afirmou que antes de praticar o tráfico de drogas, procurou por emprego, porém não teve oportunidades. Tem passagem pela polícia por outros delitos. O interrogado mostrou onde estavam as drogas aos policiais. Afirmou que os policiais invadiram a residência do acusado sem autorização. Não conhecia os policiais. Afirmou que Kelvin não foi preso porque o réu assumiu toda a droga, pois realmente Kelvin não tinha nada a ver com o tráfico de drogas. Nega que a residência do interrogado era ponto de droga, afirma que só vendia as drogas fora da casa. Aduziu que no momento da abordagem o réu estava no interior da residência. A porção maior do pó branco encontrado na casa do acusado era farinha de trigo, e nega que usava esse pó para misturar na cocaína. Em todo momento colaborou com a ação policial. O valor de R\$ 20,00 encontrado no imóvel do interrogado era para colocar gasolina na motocicleta (fl. 153).

O Policial Militar João Alex obtemperou que estava em patrulhamento pelo Bairro Nova Florínea, quando recebeu uma informação de que o réu, conhecido como 'Romano', estaria traficando drogas em sua residência. O depoente se deslocou até o local, sendo possível visualizar o acusado em frente à casa. Imediatamente abordado, o réu tinha duas porções de cocaína embaladas em sacos transparente, salvo engano. Em primeiro momento, o acusado negou a traficância. O depoente fez contato com outro morador da casa, de nome Kelvin, e esse negou que havia mais drogas dentro da residência. Kelvin franqueou a entrada do depoente na casa do acusado. Durante a vistoria pelo imóvel, foi localizado no quarto do réu um pote de fermento biológico contendo mais 19 porções de cocaína envoltas nos mesmos moldes das encontradas em posse do acusado, além de 12 pedras de crack, R\$ 20,00 em espécie, balança de precisão e embalagens plásticas. Havia também uma mistura de pó branco no quarto do acusado, no qual o depoente não conseguiu identificar prontamente do que se tratava, tendo o réu aduzido que seria uma mistura para 'render' mais a droga vendida. Kelvin afirmou que dividia o aluguel com o acusado. Posteriormente, quando o depoente achou todas as drogas, bem como os petrechos para embalagem dos entorpecentes, o réu admitiu a traficância e revelou que a mistura branca encontrada pelo depoente era usada para aumentar a cocaína, fazendo com que a droga rendesse mais. Não houve resistência pelo acusado. O réu disse que vendia por R\$ 20,00 cada porção de cocaína e por R\$ 10,00 cada pedra de crack. Já conhecia o acusado por outros crimes praticados. Em entrevista com Kelvin, este disse que não tinha conhecimento dos fatos, pois trabalha o dia todo fora e somente divide o aluguel com o réu. O acusado confirmou essa informação. Não se recorda se foi feita a declaração escrita de autorização para entrada do depoente na residência (fl. 153).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Marcos tendo aduzido que já tinha informações anteriores aos fatos de que o réu estaria praticando o tráfico de drogas no local. Não tinha conhecimento sobre as drogas e apenas dividia a casa com o acusado, tanto que tinha acabado de chegar do serviço e o réu ratificou o não conhecimento por parte de Kelvin (fl. 153).

A testemunha Kelvin asseverou que na época dos fatos estava, há dois meses, dividindo o aluguel com o acusado, pois o depoente estava passando por problemas pessoais. Afirmou que conhece o réu desde pequeno e nunca viu o acusado praticando o tráfico de drogas. Os policiais invadiram a casa do depoente. Os policiais pediram para o réu e o depoente se sentarem no chão e começaram a indagar sobre as drogas. Não autorizou a entrada dos policiais na residência. Asseverou que durante a busca

dos castrenses pela casa, o depoente ficou sentado no quintal junto com o acusado. Não foi apresentada nenhuma droga encontrada ao depoente. Afirma que o réu que indicou aos policiais onde estavam guardadas as drogas. Nega que tenha dito que a residência do acusado era uma 'biqueira'. Assinou o termo de depoimento na fase policial sem ler. Recorda-se de ter conversado com o Delegado, mas não lembra o nome. Nunca viu nenhum objeto que se destinava ao tráfico de drogas dentro da residência (fl. 153).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita, bem como pela confissão extrajudicial e judicial. É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do tráfico de drogas, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a notícia recebida pelos policiais de que o acusado realizava o tráfico, o que ensejou o patrulhamento pelos castrenses pelas vias da cidade, a quantidade e forma de embalagem do entorpecente apreendido em posse do réu, a apreensão de dinheiro, de balança de precisão e de embalagens plásticas, o que bem demonstra a finalidade de mercancia, ressaltando-se, ainda, a confissão. Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Ressalta-se, por oportuno, que se o acusado foi detido em estado de flagrância, mantendo consigo entorpecente, ilicitude penal esta de natureza permanente, não há que se asseverar a ocorrência de prisão ilegal, por falta de mandado de busca e apreensão, já que caracterizada a hipótese excepcionalizada pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (cf. STJ, HC 26.929/RR, 5ª Turma Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 18/08/2003).

Ademais, vale ressaltar que os policiais foram categóricos, na fase policial e em Juízo, ao afirmarem que a testemunha Kelvin autorizou a entrada no imóvel, o que, aliás, encontra respaldo na confissão judicial, com riqueza de detalhes, e no estado de flagrância ratificado pelos testigos coligidos sob o crivo do

contraditório.

No mesmo diapasão:

Quanto à alegação de ilicitude das provas decorrentes do flagrante, como é cediço, havendo flagrante em crime de tráfico ilícito de substância entorpecentes - infração penal de natureza permanente -, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial. Caracterizada, em princípio, a prática do delito de tráfico de entorpecente, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do investigado ou suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno (TJ-BA - HC: 00217898420168050000, Relator: José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 16/02/2017).

No mesmo sentido:

Nulidade - Tráfico de entorpecentes - Agente flagrado com 04 porções de maconha, mantendo em depósito outras 47 porções de cocaína sob a forma de crack - Ausência de prévio mandado judicial de busca e apreensão - Situação de flagrante cuja concretização é hábil para confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões que justificavam a adoção da medida - Inocorrência [...] O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema n.º 280, observou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial será lícita, mesmo em período noturno, desde que venha "amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". Conclui-se, portanto, que, conquanto seja efetivamente recomendável que aludida entrada forçada em domicílio venha, sempre que possível, precedida de mandado judicial, de tal sorte a respaldar previamente a conduta dos policiais na hipótese de a diligência ser infrutífera, fato é que eventual concretização do flagrante será evidentemente hábil a confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões justificando a adoção da medida pela situação de flagrante delito. Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo 04 porções de maconha e tem em depósito 47 porções de crack - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados àqueles de "trazer consigo" e de "ter em depósito". (TJ-SP - APR: 15013977820208260047 SP 1501397-78.2020.8.26.0047, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/05/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/05/2021).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.1. Passo à dosimetria da pena.

O acusado é reincidente (Ações Penais nºs 0007996-78.2018.8.26.0047 e 1500052-30.2020.8.26.0580) - cf. Certidões e F.A de fls. 45/47 e 48/51.

Logo, fixa-se a pena base no mínimo legal.

Em seguida, em razão da reincidência, elevo a reprimenda em 1/5, e a reduzo em 1/6, em razão da confissão.

Por fim, a reincidência desautoriza a aplicação causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

No tocante à detração penal antes da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em que pese a existência da disposição do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.736/12, entendo inviável o cômputo no presente momento do período de prisão cautelar já cumprido, pois somente em sede de execução criminal é possível a realização do referido cálculo com segurança.

De se convir que eventual lacuna da Folha de Antecedentes pode levar a que um réu que esteja com prisão cautelar decretada em mais de um feito criminal e que tenha detraído em duplicidade o período de encarceramento provisório, equívoco que

poderia acabar coberto pela imutabilidade da coisa julgada caso operada a prematura detração em sede de sentença, o que não se pode admitir. Observo, ainda, que para a progressão de regime devem ser examinados outros requisitos, que não só o objetivo, de forma que, para uma análise segura, a detração seja feita somente na fase de execução, quando a centralização das informações carcerárias do acusado ensejará a realização de cálculo confiável.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, em razão da reincidência e da gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo.

O montante da pena corporal e a reincidência desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, em virtude da reincidência e tendo em vista que tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerente ao delito, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro apreendido em favor da União, destruindo-se os instrumentos do crime - embalagens plásticas e balança de precisão (fls. 12/13).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Assis, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA